



ANALISTA
FLÁVIO ROLIM
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AULA 10 (AULA 2 DO PROF)

ROTEIRO DE AULA

Tema: Teoria Geral das Provas

1. Classificação das Provas: quanto à finalidade
2. Prova emprestada.
3. Compartilhamento de dados fiscais e bancários
4. Provas produzidas no estrangeiro.
5. Provas Cautelares, Não repetíveis e Antecipadas e Análise do Art. 155, CPP
6. Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas e análise do art. 155, CPP.
7. Ônus da Prova
8. Conceito
9. Ônus da Prova Objetivo e Subjetivo
10. Distribuição do ônus da Prova
11. Ônus da prova distribuído
12. O papel do juiz na gestão da prova

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FINALIDADE

➤ **Prova anômala** □ É aquela produzida com base em procedimento legal, contudo, adota-se procedimento distinto daquele especificamente determinado para a produção daquele tipo de prova. Trata-se de severo **vício de finalidade** com a utilização de um meio de prova previsto e válido, contudo para finalidade distinta e, portanto, imprópria para aquele fim. Ex. ao invés de expedir a carta precatória para a oitiva de testemunha que se encontra em outro Estado, adota-se certidão do oficial de justiça, que entra em contato com a vítima e toma o seu depoimento. Saiba que o vício, para maioria dos doutrinadores, se trata de nulidade absoluta. De outro modo, para outros doutrinadores, é uma prova inadmissível, e, por fim, ainda outros defendem ser a prova ilícita.

➤ **Prova irritual** □ É a prova típica que é produzida em desconformidade com o modelo legalmente estabelecido. Ex. oitiva da vítima de um crime sexual por escrito. A doutrina costuma apontar como vício de natureza relativa.

A esse respeito, Guilherme Madeira pontua:

(...) a prova anômala é produzida segundo o modelo legal. Seu problema consiste em que o modelo legal utilizado não é o adequado para o caso, não é o que o caso requer. Já a prova irritual não é produzida segundo o modelo legal. Em verdade, utiliza-se o meio adequado, mas sem a observância dos elementos típicos previstos em lei. Ou seja, na prova anômala segue-se o procedimento previsto em lei, mas não o procedimento previsto para aquele meio de prova. Na prova irritual segue-se o procedimento previsto para o meio de prova, mas sem a observância do modelo previsto em lei.

A respeito da prova atípica, o STJ entendeu que a “autópsia psicológica” constitui prova atípica admissível no processo penal, cabendo ao magistrado controlar a sua utilização no caso concreto:

Não vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos meios de prova, sendo admitida a produção de provas não disciplinadas em lei, desde que obedecidas determinadas restrições. A análise sobre a validade da prova atípica perpassa, pois, pelo campo epistemológico.

Não existe um dispositivo específico que trate sobre as provas atípicas no CPP. No entanto, é possível utilizar, por analogia - como autoriza o art. 3º do CPP -, o art. 369 do CPC.

Significa dizer, em última análise, que o rol de provas previsto no Título VII do CPP é exemplificativo.

Assim, o simples fato de não constar do catálogo legal relacionado às “provas em espécie” não configura razão suficiente para que a perícia ora impugnada seja considerada inadmissível.

A “autópsia psicológica”, raras vezes utilizada na praxis forense brasileira, consiste em exame retrospectivo que busca compreender os aspectos psicológicos envolvidos em mortes não esclarecidas.

A “autópsia psicológica” não constitui prova ilícita ou ilegítima, razão pela qual não deverá ser desentranhada. Além disso, é admissível, por ser possível ser refutada - seja porque há indicação das fontes originárias dos depoimentos, preservando a cadeia de custódia, seja porque os assistentes técnicos puderam contestar sua cientificidade no curso do processo.

No entanto, trata-se de prova ainda não padronizada pela comunidade científica e erigida, inegavelmente, em aspectos subjetivos.

Assim, incumbirá aos jurados, juízes naturais da causa, realizar o cauteloso cotejo do referido laudo com o restante do acervo probatório acostado aos autos.

STJ. 6ª Turma. HC 740431-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2022 (Info Especial 10).

A respeito da autópsia psicológica, vejamos interessante explicação a respeito do assunto: *“A autópsia psicológica pode ser definida como um tipo de avaliação psicológica realizada retrospectivamente através de uma investigação imparcial, que objetiva compreender os aspectos psicológicos de uma determinada morte. Busca-se compreender o que havia na mente do indivíduo. Ela visa reconstruir a vida psicológica de um indivíduo, analisando o seu estilo de vida, a personalidade, a saúde mental, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos precedentes a morte, a fim de alcançar um maior entendimento sobre as circunstâncias que contribuíram para o fato. Além disso, a autópsia psicológica pode auxiliar no esclarecimento do modo da morte, que pode ser natural, acidental, por suicídio ou homicídio.”*

PROVA EMPRESTADA.

A prova emprestada funciona como clara expressão do princípio da economia processual. Trata daquelas situações em que determinada prova produzida em determinado processo é transportada para outro com a aptidão de influenciar o julgador em sua decisão.

A professor ADA PELLEGRINI GRINOVER, em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, no 4, out./dez. 1993, p. 60, conceitua-a como “aquela que é produzida num processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, visando a gerar efeitos em processo distinto”.

Conforme as lições de Paulo Rangel, trata-se de meio de prova inominada, que, quanto à forma, será sempre documental.

-REPERCUSSÃO DA ECONOMIA PROCESSUAL

-FORMA SEMPRE SERÁ DOCUMENTAL

- MEIO DE PROVA INOMINADO

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: [FGV - 2026 - TJ-RJ - Técnico de Atividade Judiciária - Sem Especialidade](#)

Em procedimento no Tribunal do Júri em razão da imputação da prática do crime de homicídio cometido por Fausto, o Ministério Público requereu, durante a instrução preliminar em juízo, observados o contraditório, o devido processo legal e as regras de competência, que fosse juntado aos autos depoimento do mesmo acusado, que se encontrava em outro processo anterior, no qual Fausto também era réu e que se processou naquele mesmo juízo. Relativamente à possibilidade, ou não, de se trasladar o referido depoimento de Fausto para o processo atual e neste ser utilizado, é correto afirmar, segundo a doutrina, que sua utilização:

A será possível, em razão do princípio da comunhão das provas no processo penal;

B será possível, em razão da viabilidade de se utilizar a prova emprestada no processo penal;

C não será possível, por violação do princípio da fiabilidade das provas;

D será possível, em razão do princípio da íntima convicção motivada do juiz;

E não será possível, em razão da ilicitude probatória por derivação.

Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [TJ-BA](#) **Prova:** [FGV - 2026 - TJ-BA - Juiz Substituto](#)

Mateus foi denunciado em razão da prática do crime de latrocínio contra Artur. Durante a instrução criminal, o Ministério Público juntou aos autos cópias de trechos de interceptações telefônicas obtidas sem autorização judicial, que foram produzidas em outro processo, no qual Mateus também fora acusado. Contudo, o Ministério Público não requisitou que viesse aos autos o laudo de confronto balístico realizado.

Diante desse cenário, o juiz, com vistas a dirimir dúvida sobre ponto relevante:

A poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá determinar que a prova juntada pelo Ministério Público seja desentranhada dos autos em razão de sua ilicitude;

B poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, purgando a sua ilicitude derivada diante da fonte independente;

C não poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá determinar que a prova juntada pelo Ministério Público seja desentranhada dos autos em razão de sua ilicitude derivada;

D poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, diante do princípio da busca da verdade real no processo penal;

E não poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, diante do princípio da busca da verdade real no processo penal.

A doutrina majoritária posiciona-se favoravelmente à possibilidade de provas emprestadas, exigindo-se basicamente dois REQUISITOS:

- Exigência de **contraditório**
- **Formalidades:** produção da prova
- **Obs.** a similaridade de partes e de fatos não são exigidos mais (requisitos não unânimes; apenas parte da doutrina considera)

Não tem prevalecido no cenário jurisprudencial brasileiro a exigência de similaridade de partes, inclusive, esse tema foi objeto de cobrança na prova do Ministério Público do Paraná no ano de 2025, vejamos a questão adaptada:

(C) É admissível a utilização de prova emprestada, desde que seja garantido o contraditório, mesmo que diferido, no processo receptor, não sendo necessária a identidade absoluta de partes.

Norberto Avena relata que, “como prova emprestada, compreende-se aquela que, produzida originariamente em um determinado processo, vem a ser apresentada, documentalmente, em outro. Para que seja admissível, é preciso que

ambos os feitos envolvam as mesmas partes e que, na respectiva produção, tenha sido observado o contraditório. Satisfeitas estas duas condições, terá a prova emprestada o mesmo valor das demais provas realizadas dentro do processo.”

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

STJ - Súmula 591: É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, foi fixada a Tese no tema 1238 – Repercussão Geral: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”. [ARE 1316369 RG, julgado em 08/12/2022.](#)

É inadmissível a condenação, em processo administrativo disciplinar, amparada em prova penal emprestada considerada ilícita, ainda que essa ilicitude tenha sido declarada posteriormente à conclusão do PAD.

[AgRg na Rcl 47.632-DE](#), Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em 10/12/2025, DJEN 23/12/2025.

Bloco 2

Em outro recente posicionamento datado de 2026, decidiu o STJ:

A extinção, sem resolução de mérito, da ação cível de produção antecipada de provas por inadequação da via eleita não implica, por si só, inutilização ou invalidade das provas, se ausente declaração de ilicitude, podendo ser legitimamente compartilhadas para fins penais, observados os requisitos legais e constitucionais.

[AgRg no RMS 77.635-SP](#), Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 12/5/2026, DJEN 25/5/2026.

O tema foi objeto de cobrança na prova discursiva para o Cargo de Promotor de Justiça do Estado do Paraná, vejamos o questionamento:

Uma vez regularmente autorizada pelo juiz competente a realização de interceptação telefônica para o fim de investigação criminal nos termos da Lei nº 9.296/96, é cabível que o mesmo juiz autorize o compartilhamento dos elementos probatórios obtidos, a título de prova emprestada, com processo administrativo disciplinar instaurado contra a mesma pessoa investigada? (0,5 ponto)

Muito cuidado: Em relação à similaridade de partes, nos parece que ambos os tribunais superiores têm flexibilizado essa exigência, vejamos alguns precedentes:

[...] "Conforme entendimento desta Corte Superior, uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua

utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida" (AgRg no AREsp 1.104.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/12/2018) (HC 446.296/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2019). (AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. **PROVA EMPRESTADA**. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA EM FORO DISTINTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa." (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021,)

2. O compartilhamento de provas não importa no traslado da discussão de toda a cadeia de custódia ao processo receptor, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, situação que será resolvida em procedimentos próprios, e.g., conflito de competência ou aplicação de institutos como o da continência ou conexão, e não pela presente via, mediante recurso ordinário em habeas corpus, instrumento de estreitos limites cognitivos cujo objetivo é o de garantir o direito de locomoção constrangido ilegalmente ou em vias de ser restringido de forma ilícita.

AgRg no RHC 169223 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2022/0248352-2; Relator Min. Saldanha Palheiros; 6ª Turma, julgado em 12/08/2024.

Paulo Rangel, em sentido minoritário, aponta requisitos para que seja lícita a prova emprestada no âmbito processual:

- **Similaridade de partes.**
- Observância das formalidades legais no processo originário.
- O fato a ser provado deve ser o mesmo.
- Pleno exercício do **contraditório** no processo do qual a prova será transferida.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS. (procedimento administrativo fiscal para constituição de crédito tributário e RIF's – relatório de inteligência financeira)

O STF, em repercussão geral, pacificou o tema e entendeu que é possível o **compartilhamento** com os órgãos encarregados de poder de investigação de dados bancários e fiscais, obtidos pela Receita Federal e pela UIF (COAF).

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações

formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Essa é a tese do **Tema 990** da Repercussão Geral fixada, por maioria, pelo Plenário (Informativos 960 e 961). Vencido o ministro Marco Aurélio, que não referendou a tese. (RE 1055941/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4.12.2019).

O tema 990-STF tem sido objeto de cobrança em concursos relevantes, vejamos:

Ano: 2024 Banca: [VUNESP](#) Órgão: [MPE-RO](#) Prova: [VUNESP - 2024 - MPE-RO - Promotor de Justiça Substituto](#)

Haja vista o envio de relatórios de inteligências financeiras pelo COAF, no exercício de suas atribuições, reportando ao Ministério Público movimentações financeiras suspeitas de X, funcionário público, e de seus familiares, é requisitada a instauração de Inquérito Policial, o que é atendido pela autoridade competente. (...)

Questão Adaptada (E) O procedimento, como um todo, estaria maculado por vício originário (ilicitude de prova), sendo vedado ao órgão de fiscalização (COAF) enviar ao Ministério Público informações bancárias sem autorização judicial.

Ano: 2025 Banca: [FGV](#) Órgão: [TJ-SE](#) Prova: [FGV - 2025 - TJ-SE - Juiz Substituto](#)

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enviou, espontaneamente, ao Ministério Público um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), segundo o qual o casal Ferdinando e Imelda e seis sociedades empresárias das quais ambos são sócios apresentam movimentação financeira atípica. O promotor de justiça instaurou notícia de fato, no bojo da qual diligência de campo revelou que não há qualquer atividade econômica em andamento nos endereços apontados como sedes das seis sociedades empresárias. Além disso, pesquisas em fontes abertas, especialmente redes sociais, mostraram que o casal Ferdinando e Imelda ostenta elevado padrão de vida, com carros importados, viagens de luxo e jantares em restaurantes caros. Em diversas postagens, o casal aparece na companhia de Alfredo, integrante de família conhecida na Comarca pelo envolvimento com a contravenção penal do jogo do bicho.

Há, no mesmo órgão ministerial, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) em que Alfredo é investigado, já presentes robustos elementos de convicção no sentido da prática da referida contravenção. O promotor de justiça reuniu a notícia de fato ao PIC e aditou a portaria de instauração para incluir o casal e novo objeto, vale dizer, o crime de lavagem de dinheiro. Prosseguindo as diligências, solicitou o Ministério Público ao COAF, via sistema institucional, informações financeiras acerca de Alfredo. A resposta do COAF foi positiva, e o órgão remeteu ao Ministério Público um RIF que aponta movimentações financeiras atípicas por parte de Alfredo.

O promotor de justiça requereu judicialmente a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Ferdinando e Imelda, das sociedades empresárias titularizadas por ambos e de Alfredo.

Com base na Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, o magistrado deverá:

A deferir integralmente a pretensão do Ministério Público;

B indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, porque o crime de lavagem de dinheiro admite, como antecedente, crime, mas não contravenção penal;

C indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, sob o fundamento da nulidade das provas, haja vista que o intercâmbio de informações financeiras entre o COAF e os órgãos de investigação, sem autorização judicial, viola o sigilo bancário e, por conseguinte, a privacidade dos investigados;

D deferir parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancário apenas quanto ao alvo Alfredo e anular as provas quanto ao casal Ferdinando e Imelda e às sociedades empresárias, porque o COAF não pode, espontaneamente, enviar informações financeiras aos órgãos de investigação;

E indeferir o pedido, sob o fundamento da nulidade das provas, porque a ilegalidade da atuação espontânea do COAF em relação aos investigados Ferdinando e Imelda e suas sociedades empresárias contamina os demais elementos de convicção presentes na investigação.

Ano: 2026 **Banca:** [VUNESP](#) **Órgão:** [MPE-SC](#) **Prova:** [VUNESP - 2026 - MPE-SC - Promotor de Justiça Substituto](#)

Adaptada (E) No julgamento do Tema 990, o STF firmou o entendimento de que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da Receita Federal com os órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial. Tal intercâmbio dispensa rigores formais, desde que seja preservado o sigilo das informações e assegurado o posterior controle jurisdicional.

O tema foi cobrado nas provas discursivas do MPU/2025 e TJSC/2025 (Sentença).

Posteriormente, por meio de julgado capitaneado pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, julgado em 15/08/2023, entendeu que a tese firmada no tema 990 não abrangeria os relatórios do COAF, solicitados pelos órgãos de persecução, assim entendeu-se que é ilícito aos órgão persecução penal requisitarem diretamente os RIFs da UIF sem autorização judicial.

Ocorre que o STF, no âmbito da Rcl 61944 AgR / PA – PARÁ de relatoria do Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, julgamento: 02/04/2024, **entendeu que não é legítima a diferenciação operada pelo STJ.**

Uniformização do entendimento no STJ sobre a requisição direta de RIFs

Em 28 de maio de 2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 196.150/GO, uniformizou a jurisprudência das Turmas criminais da Corte no sentido de que a Polícia e o Ministério Público não podem requisitar diretamente ao COAF Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs sem prévia autorização judicial.

Segundo o entendimento prevalecente, a tese fixada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral autoriza o compartilhamento, independentemente de ordem judicial, quando a iniciativa parte dos próprios órgãos de inteligência ou fiscalização. Assim, constatada situação suspeita no exercício de suas atribuições, COAF e Receita Federal podem encaminhar espontaneamente as informações aos órgãos de persecução penal.

Desse modo, segundo a orientação uniformizada pelo STJ:

- COAF/RFB → Polícia ou Ministério Público, por iniciativa do órgão de inteligência ou fiscalização: admite-se o compartilhamento sem prévia autorização judicial, nos termos do Tema 990/STF.,

- *Polícia ou Ministério Público → solicitação direta ao COAF para obtenção de RIF: exige-se, segundo a Terceira Seção do STJ, prévia autorização judicial.*

SUSPENSÃO NACIONAL E DISCIPLINA PROVISÓRIA DO TEMA 1.404/STF

- **20/08/25:** suspensão dos processos
- **25/08/25:** suspensão não impede o prosseguimento das investigações; a suspensão são dos efeitos das decisões que determinaram a anulação dos RIFs
- **27/03/26:** tema 1404 STF; requisitos provisórios para a utilização dos RIFs a pedido:
 - investigação formalmente instaurada
 - identificação do investigado pertinência entre pedido e investigação
 - vedação ao fishing Expedition
 - RIF não pode ser primeira e nem única medida investigativa
- **21/04/26:** esses parâmetros possuem efeito ex nunc

Bloco 3

PROVAS PRODUZIDAS NO ESTRANGEIRO.

Por fim, o STJ reconheceu também a **validade da utilização de provas produzidas no estrangeiro em processos brasileiros**, desde que sejam amplamente cumpridas as disposições da LINDB:

Art. 13 da LINDB: “A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.”

Art. 17 DA LINDB: “As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.”

Vejamos o entendimento do referido tribunal:

[...] 2. As provas obtidas por meio de cooperação internacional em matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do Estado no qual foram produzidas, conforme a previsão do art. 13 da LINDB. 3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso no território nacional se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da LINDB. [...] 6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro são legítimas, segundo o parâmetro de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente na cadeia causal, a qual afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, portanto, razões para a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo. (APn 856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017).

Renato Brasileiro ainda faz importante questionamento:

Seria possível o empréstimo de elementos informativos?

Obs. lembrando: elementos informativos - são aqueles produzidos no momento da investigação preliminar (que é mais ampla e pode abranger o IP)

Inicialmente, considerando que a premissa para que haja o empréstimo de provas é a existência de regular contraditório no processo de origem, **NÃO** seria possível o empréstimo de elementos informativos. Pois, em relação a eles, não há contraditório.

Renato **excepciona** a referida informação quando se tratar de provas não repetíveis produzidas no âmbito do inquérito policial, pois, nestes casos, invariavelmente, o contraditório, mesmo no processo de origem, é realizado de modo diferido. Perceba que a exceção se trata das **provas CAI/CIA**.

Obs. 2. Lembre-se que as provas produzidas em âmbito de IP podem ser emprestadas.

Por fim, um último questionamento:

Qual o valor da prova emprestada no processo em que ingressa?

Inicialmente, considerando o sistema do livre convencimento motivado existente no ordenamento jurídico brasileiro, tratar a respeito do valor de determinada prova não se mostra produtivo, contudo, é tema tratado no âmbito da doutrina, inclusive possibilitando a aplicação analógica do artigo 372, CPC:

Art. 372 do CPC: "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."

Vejam os ensinamentos de Renato Brasileiro a respeito:

Embora seja trazida ao segundo processo pela forma documentada, a prova emprestada tem o mesmo valor da prova originalmente produzida. Ou seja, apesar de sempre ter a forma documental, o valor probante da prova emprestada "é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo". Assim, no exemplo citado acima, conquanto o depoimento de "Mévio" seja trazido ao segundo processo por meio de uma certidão extraída do processo original, seu valor probatório será o de prova testemunhal (Lima, 2018).

A nulidade do processo originário gera a nulidade de todas as provas nele produzidas?

- Necessário verificar se a nulidade ocorreu por ilicitude da prova: se sim, as provas estarão anuladas
- Contudo, se a nulidade não for por questões relativas à prova: as provas estariam preservadas

Ano: 2024 Banca: [CESPE / CEBRASPE](#) Órgão: [DPE-AC](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2024 - DPE-AC - Defensor Público](#).

No que se refere à prova emprestada, conforme as normas do direito processual penal brasileiro, julgue os próximos itens.

I É inadmissível a utilização de prova emprestada quando as partes forem diferentes.

II É assegurada a utilização de prova emprestada, desde que seja assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados.

III Não pode ser admitida prova emprestada se produzida em inquérito distinto daquele no qual se pretende utilizá-la.

Assinale a opção correta.

- a. Apenas o item II está certo.**
- b. Apenas o item III está certo.
- c. Apenas os itens I e II estão certos.
- d. Apenas os itens I e III estão certos.
- e. Todos os itens estão certos.

O tema foi novamente enfrentado na prova do Ministério Público do Estado da Bahia no ano de 2023, vejamos:

Adaptada (E) Segundo a jurisprudência do STJ, a absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada é necessária para a observância do devido processo legal e do contraditório

PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS E ANÁLISE DO ART. 155, CPP.

Dentro do estudo da teoria geral das provas, é necessário o estudo do artigo 155, CPP, o qual possui a seguinte redação.

Art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Para que possamos analisar esse dispositivo, inicialmente, deve-se conceituar com clareza o sentido das provas Cautelares, Irrepetíveis e Antecipadas.

As **Provas Cautelares** são aquelas que seguem o modelo das demais medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico processual, as quais se concretizam pelo “*fumus comissi delict* e *periculum in mora*”. **O risco da demora ou desaparecimento é a característica mais marcante** das provas cautelares, as quais, ordinariamente, submetem-se à CLÁUSULA DE RESERVA JURISDICIONAL. Podem ser produzidas tanto na fase inquisitória, o que é mais comum, ou na fase processual, em ambas as situações o contraditório é exercido de forma diferida ou postergada. (ex. interceptação telefônica)

As **Provas Não Repetíveis** (irrepetíveis) são aquelas que, uma vez produzidas, não são passíveis de renovação, motivo pelo qual também possuem o elemento urgência como fenômeno diretamente correlacionado. Estar-se-á a falar,

normalmente, dos exames periciais. NÃO se sujeitam à cláusula de reserva jurisdicional e contam com CONTRADITÓRIO diferido ou postergado.

Por fim, as **Provas Antecipadas** são aquelas que devem ser produzidas antes do momento devido para a produção probatória em INCIDENTE PRÓPRIO (incidente de produção antecipada de provas) e com CONTRADITÓRIO contemporâneo. Vejamos os dispositivos que fazem referência a esse tipo de prova:

Art. 225 do CPP: “Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o **depoimento**.” (já caiu em prova) (**depoimento ad perpetuum rei memoriam**)

Art. 366 do CPP: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no [art. 312](#). [\(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996\)](#)”

Vejamos dispositivo do CPC que trata especificamente a respeito da produção antecipada de provas:

Art. 381 do CPC: “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

- I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
- II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
- III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

O tema é frequente em provas:

O tema foi cobrado na prova do MPDFT, vejamos a questão adaptada:

(E) As perícias produzidas no inquérito precisam ser repetidas no curso da ação penal para que possam serem utilizadas como base de condenação, nos moldes do artigo 155 do CPP.

O STJ tem sucessivamente manifestado-se a respeito das provas irrepitíveis, vejamos alguns julgados recentes:

Reconhecimento de Pessoas - Prova Irrepetível.

ATENÇÃO: a irrepitibilidade não decorre necessariamente do desaparecimento físico do objeto da prova. No Tema 1.258, o STJ reconheceu que o reconhecimento de pessoas possui natureza irrepitível em razão do risco de contaminação da memória do reconhecedor. Um reconhecimento inicial viciado pode comprometer o procedimento posterior, ainda que este venha a observar formalmente o art. 226 do CPP.

1) As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a

condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2) Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3) O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do art. 226 do CPP.

4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

[REsp 1.953.602-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025. ([Tema 1258](#)). [REsp 1.987.628-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)). [REsp 1.986.619-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)). [REsp 1.987.651-RS](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)).

Em outra oportunidade, irrepetibilidade da testemunha que faleceu antes da instrução processual.

No AgRg no RHC 227.441, publicado em 30/3/2026, o STJ enfrentou um homicídio em que uma testemunha havia prestado depoimento durante o inquérito e faleceu antes da instrução judicial.

A Corte decidiu:

O depoimento prestado na fase policial por testemunha que venha a falecer antes da instrução constitui prova irrepetível. Brasília, 25 de março de 2026 . JOEL ILAN PACIORNIK.

Teste de etilômetro.

No AgRg no AREsp 3.128.529/AP, Quinta Turma, julgado em maio de 2026, discutia-se o crime de embriaguez ao volante. Havia teste de etilômetro, considerado prova irrepetível, mas os policiais ouvidos em juízo já não se recordavam de quem dirigia o veículo. O STJ afirmou:

A prova irrepetível pode ser valorada, mas não supre a ausência de prova judicial da autoria.

O etilômetro demonstrava a alcoolemia da pessoa submetida ao exame, mas isso não solucionava, por si só, a questão de saber se era efetivamente ela quem conduzia o automóvel.

O resultado foi a manutenção da absolvição.

Brasília, 12 de maio de 2026 . Ministro Ribeiro Dantas.

Bloco 4

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

Art. 366. *Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no [art. 312](#).*

O Tema foi cobrado na prova do Ministério Público do Estado de Goiás no ano de 2026, vejamos:

Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [MPE-GO](#) **Prova:** [FGV - 2026 - MPE-GO - Promotora e Promotor de Justiça Substituto](#)

O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em face de Caio pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. Após a observância de todas as formalidades legais, designou-se data para a realização da instrução processual. No dia da audiência, o acusado não compareceu, embora sua defesa constituída estivesse presente. Ao analisar os autos, as partes da relação processual constataram que Caio mudou de residência, não tendo comunicado o novo endereço ao juízo.

Nessa conjuntura, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a audiência de instrução será

A *suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por meio da defesa constituída.*

B *suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por carta precatória.*

C *realizada sem a presença do acusado, desde que haja concordância da defesa constituída.*

D *suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por edital.*

E *realizada sem a presença do acusado, com a decretação de sua revelia.*

O Tema foi cobrado na prova do Ministério Público do Estado de Goiás no ano de 2026, vejamos:

Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [TJ-SC](#) **Prova:** [FGV - 2026 - TJ-SC - Oficial de Justiça e Avaliador](#)

Em um processo que apura a prática de crime de estelionato, o oficial de justiça tentou localizar o réu nos endereços constantes nos autos, sem sucesso. Após certificar que o réu se encontra em local incerto e não sabido, o magistrado determinou a citação por edital. O edital foi publicado com prazo de 15 dias, mas, decorrido o prazo, o réu não compareceu e não constituiu advogado para representá-lo.

Diante de tal situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

A O juiz deverá nomear defensor dativo e dar prosseguimento ao processo até a sentença, uma vez que a citação por edital é válida para fins de prosseguimento da ação.

B O processo deverá ser suspenso, assim como o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva.

C A citação por edital é considerada nula se não for precedida de citação por hora certa, devendo o juiz determinar nova diligência antes de qualquer decisão sobre a suspensão do feito.

D O juiz deve declarar a revelia do réu e encaminhar os autos ao Ministério Público para que o órgão realize a busca do endereço atualizado, mantendo-se o curso da prescrição.

E Por se tratar de crime de estelionato, a suspensão do processo depende de prévia concordância da vítima, que deverá ser intimada para manifestar interesse no prosseguimento da lide.

(CPP) Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

MPPR/2025.

(E) A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do Código de Processo Penal pode ser fundamentada unicamente no decurso do tempo para se ter como urgente a antecipação probatória.

(MPDFT) - Promotor de Justiça (MPDFT)/2013/30º. Interprete o seguinte dispositivo legal, extraindo-lhe todos os significados possíveis, particularmente em relação aos termos destacados abaixo.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da **prova produzida em contraditório judicial**, não podendo fundamentar sua decisão **exclusivamente** nos **elementos informativos** colhidos na investigação, ressalvadas as provas **cautelares, não repetíveis e antecipadas**.

(MPE PR) - Promotor de Justiça/2017. Acerca da prova no processo penal:

A) Defina o que são provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, esclarecendo se a legislação processual penal permite que sejam utilizadas na formação da convicção do julgador (valoração como material probante) quando produzidas na fase de investigação.

B) Leia a hipótese do Enunciado a seguir e responda, fundamentadamente, se está correta a pretendida solução absolutória requerida por ausência de prova da materialidade. ADELICIO LIMA SILVA foi denunciado e processado por

estupro de vulnerável (art. 217- A, do Código Penal), sob a acusação de ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança A.F.R., de 10 (dez) anos de idade, consistente em acariciar e beijar a vagina da infante. No transcorrer da instrução, sobreveio aos autos o laudo de exame pericial a que foi submetida à vítima, com "resposta prejudicada" para os questionamentos realizados quanto à ocorrência de atos libidinosos, embora a prova testemunhal fosse harmoniosa e robusta no sentido da sua prática. Ao apresentar alegações finais do acusado ADELICIO LIMA SILVA, a Defesa pleiteia a sua absolvição, invocando, como fundamento, a ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da inexistência de laudo de exame pericial positivo.

Ainda a respeito da prova antecipada, o STJ entendeu que é justificável, em caso de depoimento especial de criança ou adolescente, a produção de prova antecipada:

É justificável a antecipação de prova no caso de depoimento especial de adolescente vítima de possível crime sexual - na forma da Lei nº 13.431/2017 - pela relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e na sua urgência pela falibilidade da memória de crianças e adolescentes.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 160012/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 6/3/2023 (Info 767).

Em outro julgado bastante relevante, o STJ admitiu a produção antecipada de provas para oitiva de policiais:

É possível a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1995527-SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 19/12/2022 (Info 764).

Esse tema foi cobrado na prova do Ministério Público do Distrito Federal no ano de 2025, vejamos:

(C) Em razão de possível esquecimento, é válida a produção antecipada de provas de agentes policiais, fundamentada unicamente no transcurso do tempo e da quantidade de ocorrências similares atendidas cotidianamente.

É importante ainda observarmos que o STJ tem entendido que a produção antecipada de provas não apresenta prejuízo à defesa, vejamos:

A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente. STJ. 3ª Seção. RHC 64086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2016 (Info 595).

Esse tema tem sido frequente em provas:

(Cespe/DPE/PE/Defensor/2018) No caso de citação por edital, se o acusado não comparecer e não constituir advogado, o processo poderá prosseguir seu curso normal, desde que para ele seja nomeado defensor público. **E**

(Cespe/TJ/PA/Analista/2020) Se um acusado, citado por edital, não comparecer para defender-se em ação penal pelo crime de falsidade ideológica, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção de provas consideradas urgentes. **C**

(MPE/PR/Promotor/2019) Se o acusado, citado por edital ou por hora certa, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. **E**

(FCC/DPE/AM/Defensor/2018) A gravidade do delito e o decurso de tempo justificam a antecipação da prova oral, porquanto a sua urgência decorre da natureza da prova testemunhal, existindo direito público subjetivo da acusação à sua produção antecipada. **E**

É interessante observar que doutrina e jurisprudência aceitam a possibilidade de que os elementos informativos sejam utilizados na atividade decisória do magistrado, desde que o façam de modo subsidiário.

Os elementos informativos podem contribuir na atividade decisória, contudo não podem ser utilizados como elemento principal ou único da atividade cognitiva.

Vejamos alguns precedentes nesse sentido:

INQUÉRITO - ELEMENTOS - CONDENAÇÃO. Surge insubsistente pronunciamento condenatório baseado, unicamente, em elementos coligidos na fase de inquérito. (HC 96356, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010). [...] INQUÉRITO.

CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. [...] Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido. (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005).

Somente a título de aprofundamento, Paulo Rangel¹ possui posicionamento em sentido **contrário**, vejamos:

“O art. 155 ressalta que o juiz não poderá fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação. Pode acontecer de o intérprete aodado entender que a palavra exclusivamente significa dizer que o juiz pode sopesar as provas do inquérito desde que em cotejo com as demais provas do processo. Nada mais equivocado. A palavra exclusivamente significa dizer que o juiz não deve levar em consideração, em sua sentença, as informações

¹ Direito processual penal, 26ª ed., São Paulo: Atlas, 2018.

contidas no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Não servem nem para cotejá-las com as do processo. Prova de inquérito é para que o MP possa dar o pontapé inicial, oferecendo denúncia.

ÔNUS DA PROVA.

CONCEITO.

Antes de efetivamente ingressarmos no conceito de ônus processual, é interessante diferenciarmos conceitos correlatos: faculdade processual, direito subjetivo, dever jurídico/obrigação e direito postestativo/poder jurídico, para esse desiderato nos valeremos das lições apresentadas pelo professor Afrânio Jardim:

*Entende-se como **faculdade jurídica** a possibilidade de fazer tudo quanto a lei não proíba e de omitir tudo quanto ela não imponha. É um campo de liberdade jurídica, decorrente da irrelevância para o direito ou da inexistência de ilicitude. Já o chamado **direito subjetivo**, numa apreciação superficial, é mais do que uma mera faculdade de fazer ou não fazer. É faculdade de exigir de outrem uma prestação. Assim, em sendo bilateral, ao direito subjetivo corresponde o **dever jurídico ou obrigação**.*

*Chama-se **direito potestativo ou poder jurídico** a faculdade, assegurada pela norma jurídica, de o seu titular submeter terceiro à sua vontade. Vale dizer, unilateralmente atinge-se a esfera jurídica do sujeito passivo, que a tudo fica submetido. Aqui, ao invés de dever ou obrigação, temos uma posição de mera sujeição à vontade de outrem.*

*Finalmente, chegamos ao **ônus processual**. Não é ele bilateral, o que torna fácil distingui-lo do direito subjetivo e poder jurídico. O ônus não é algo impositivo, imperativo. Muito pelo contrário, é uma espécie de faculdade. É um campo de liberdade que tem um determinado sujeito de direito para atuar positivamente, a fim de que venha a alcançar algum benefício em seu favor. Assim, pode-se dizer que ônus processual é uma faculdade outorgada pela norma para que um sujeito de direito possa agir no sentido de alcançar uma situação favorável no processo. Se juridicamente fosse possível, poderíamos dizer que ônus **“é o dever para consigo mesmo”** (Jardim, 2003).*

Ainda a respeito da conceituação de ônus processual, as lições do professor Hélio Tornaghi são elucidativas, vejamos:

“não se trata de um dever, mas de um ônus, um encargo. O dever existe para com outrem. Quem o tem e não o cumpre sofre pena. O encargo é uma sorte de obrigação para consigo mesmo. Se a lei encarrega alguém de praticar um ato, em seu próprio favor, e o encarregado não o realiza, a ninguém prejudica senão a si mesmo. Por isso não sofre pena; deixa de lucrar o que ganharia se o praticasse”.

Bloco 5

NORBERTO AVENA arremata o tema, ocasião em que relata que “por ônus entende-se o encargo atribuído às partes de provar, por meio de meios lícitos e legítimos, a verdade das suas alegações, visando, assim, a fornecer ao juiz os elementos necessários à formação de sua convicção”.

ÔNUS DA PROVA OBJETIVO E SUBJETIVO.

O ônus da prova **SUBJETIVO** é encargo atribuído às partes e refletem regras de conduta e comportamento quanto ao dever de prova. Já o ônus **OBJETIVO** é inerente ao juiz e reflete-se em regras de julgamento, as quais devem ser aplicadas pelo juiz quando as partes não conseguem com clareza formar a necessária cognição do juiz para um decreto decisório. Afrânio Jardim fala a esse respeito:

“a utilidade prática das regras sobre o ônus da prova está em fornecer ao Juiz critérios legais para que possa decidir mesmo diante de fatos incertos. Malgrado todo o empenho das partes e do Juiz em buscar determinada prova, constantemente ocorre que persiste dúvida sobre ponto relevante para o julgamento da pretensão punitiva. Aqui é que está o cerne da questão, pois o magistrado não pode escusar-se de julgar e, em nosso direito, não existe o instituto da suspensão do processo penal por insuficiência de provas”. O mesmo autor destaca que “quanto mais subsídios de provas existirem, quanto maior a probabilidade de um esclarecimento cabal dos fatos relevantes, na mesma proporção diminuirá a necessidade de recorrer às normas de distribuição do onus probandi. As regras do ônus da prova, consideradas como regras de julgamento, implicam na repartição do risco da prova, que é a solução necessária para os casos de impossibilidade de esclarecimento, apesar de todos os esforços (Jardim, 2003).

Com menor incidência na doutrina, Renato Brasileiro ainda fala em ônus perfeito e ônus menos perfeito, vejamos as lições:

*Ônus da prova perfeito e menos perfeito. Tendo como critério a consequência que decorre do não cumprimento do ônus, a doutrina o subdivide em ônus perfeito e menos perfeito. O ônus é **PERFEITO** quando o prejuízo, que é o resultado de seu descumprimento, ocorre necessária e inevitavelmente. Um ônus é tido como **MENOS PERFEITO** quando os prejuízos que derivam de seu descumprimento se produzem de acordo com a avaliação judicial. Com base nessa classificação, **não** se pode falar em ônus completamente imperfeito, na medida em que, quando não resultar qualquer prejuízo da inação para o omitente, não haverá ônus algum.*

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

O tema é controverso na doutrina, motivo pelo qual faremos detalhada análise a respeito do tema. Inicialmente, devemos observar a literalidade do artigo 156, CPP, vejamos a redação do dispositivo legal:

Art. 156 do CPP: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:(...)”

O art. 156 deve ser lido em consonância com o disposto no artigo 386, CPP, vejamos:

Art. 386 do CPP: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)

II - não haver prova da existência do fato; (...)

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Então, a primeira informação importante é, “quem alega, prova”. No mesmo sentido determina o CPC:

Art. 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim sendo, pode-se concluir que a distribuição do ônus, em um primeiro momento é: “acusação comprova os elementos constitutivos do tipo penal”.

Cuidado: NÃO confunda com elementos informativos, que são produzidos em fase própria, observe:

Elementos informativos

Art. 14 do CPP: “O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.”

Compreenda que a distribuição do ônus da prova, dentro do processo penal, depende do sistema de distribuição a ser adotado. A doutrina adota 2 sistemas de distribuição:

- Ônus da prova distribuído entre acusação e defesa.
- Ônus da prova estático, incumbindo somente à acusação todo o ônus probatório.

ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO.

A doutrina majoritária entende que o ônus da prova, conjugando a leitura do artigo 156 e 386, deve ser distribuído entre as partes. O CPC possui dispositivo bastante elucidativo a respeito do tema, vejamos:

Art. 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Desse modo, prevalece que à **acusação** se incumbe o ônus de provar a materialidade e a autoria, “cabendo ao **réu** a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela acusação” (Dezem, 2018).

Vejamos algumas passagens das obras de autores que se posicionam nesse sentido:

- Hélio Tornaghi:

O art. 156 do Código de Processo Penal é claro, porém menos preciso do que parece à primeira vista. Se o acusador afirma que o acusado matou e este assevera que não o fez, a quem compete a prova? Se o autor assegura que o acusado agiu ilicitamente e o réu sustenta que agiu licitamente, qual dos dois deve provar? Seria errado supor que o acusador tem de provar tudo quanto alega contra o réu. Assim, por exemplo, não lhe é necessário provar a ilicitude do fato, desde que ele seja típico, isto é, adequado à descrição legal. O promotor denuncia Tício por haver matado Caio, não precisa provar que ele o fez antijuridicamente. Ao contrário: Tício, o denunciado, é que terá de provar que o fato por ele praticado, apesar de típico, foi lícito (por exemplo, por ter agido em legítima defesa).

➤ Frederico Marques:

(...) Deduz-se de ambos os preceitos que à parte acusadora incumbe fornecer os necessários meios de prova para a demonstração da existência do corpus delicti e da autoria. Daí se segue que todos os elementos constitutivos devem ter sua existência provada, ficando o onus probandi, no caso, para a acusação. Cabe a esta demonstrar não só a chamada materialidade do crime (o que é a função do auto de corpo de delito), como ainda os elementos subjetivos e normativos do tipo [...] O Ministério Público deve provar a prática do fato típico. Feita essa demonstração fundamental, segue-se o juízo de valor sobre a licitude da conduta tipificada. Existindo uma causa excludente da antijuridicidade, o fato típico não será ilícito. Ao réu, porém, incumbe provar a existência dessa causa excludente de ilicitude, para que demonstre ter agido secundum jus. [...] Idêntico fenômeno ocorre com o ônus da prova no tocante às causas de exclusão da culpabilidade mencionadas no art. 386 [...]. Quando se trata de culpa, a sua inserção no tipo [...] faz com que o onus probandi seja do Ministério Público, quer se trate de imperícia, de imprudência ou de negligência. A prova do dolo incumbe também à acusação.

Em sentido bastante semelhante se posicionam Mirabete, Nucci, Pacelli, Norberto Avena e Vicente Greco Filho.

ÔNUS DA PROVA EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO.

Para essa corrente não haveria distribuição do ônus probatório, ao contrário, todo o ônus pesaria sobre a acusação. Nesse sentido, vejamos as lições apresentadas por Gustavo Badaró:

No processo penal, diante da garantia constitucional da presunção de inocência, não há distribuição do ônus da prova, que pesa todo sobre a acusação. Trata-se de um ônus da prova unidirecional, não havendo, pois, distribuição do ônus da prova, como ocorre no processo civil. Além disso, em decorrência da garantia constitucional da presunção de inocência, também não são admitidas no processo penal presunções legais ou judiciais contra o acusado. A doutrina é uniforme no sentido de que a dúvida sobre a conduta típica, incluindo em tal conceito a ação ou a omissão, bem como o nexo causal com o resultado naturalístico, quando estes forem exigíveis, levará a um julgamento absolutório. O ônus da prova da autoria delitiva, bem como da participação no concurso de agentes, pesa sobre a acusação. Curiosamente, contudo, tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, se o acusado alega um alibi, pesaria sobre ele o ônus da prova de demonstrar que estava em outro lugar, no momento da prática delitiva.

Em sentido contrário, Paulo Rangel, Aury Lopes e Renato Brasileiro.

Desse modo, ao menos de acordo com a doutrina majoritária, poderíamos consolidar o entendimento da seguinte maneira:

Resumo

➤ Ônus da Acusação:

- Existência do fato relevante penal.
- Autoria.
- Relação de causalidade e materialidade (***nos crimes materiais***).
- Culpa *strictu sensu* e presunção de Dolo.

➤ Ônus da Defesa:

- Fatos impeditivos: exclusão de culpa/ausência de dolo.
- Fatos modificativos: excludentes de ilicitude.
- Fatos extintivos: prescrição.

Visto isso, pode-se afirmar que, majoritariamente, tem-se o ônus distribuído entre a acusação e a defesa. Em decorrência disso precisa ser respondido a seguinte indagação:

Nível probatório exigido pela defesa.

A defesa teria então o ônus processual de demonstrar todos os elementos que comprovem que agiu em legítima defesa? Ou de comprovar por A + B que não tinha elemento subjetivo em sua conduta?

NÃO, porque o peso do ônus que pesa sobre a defesa é consideravelmente menor, já que a dúvida a favorece (ônus menos perfeito). Desse modo, ficando o juiz em dúvida, **NÃO** pode dar uma sentença desfavorável ao réu, ou seja, condenatória. Perceba que à defesa basta causar no juiz uma dúvida razoável para alcançar uma sentença absolutória.

Nesse sentido, vejamos as lições apresentadas por Aury Lopes Júnior:

Princípio importantíssimo no Estado Democrático de Direito, a lógica do in dubio pro reo é que se o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, permanecer em dúvida sobre a condenação ou absolvição do réu, deve optar pela absolvição, até porque entre duas hipóteses não ideais é menos traumático para o direito absolver um réu culpado do que admitir a condenação de um inocente.

Evidentemente, o famoso princípio do in dubio pro reo deve ter sua aplicação limitada no processo penal, uma vez que funciona como regra de julgamento a fim de evitar o non liquet do julgador, sendo certo que o ideal é sempre o juiz julgar com a certeza, seja para condenar ou para absolver.

Nesse sentido, são as disposições do artigo 386, CPP, vejamos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Mesmo porque, em processo penal, incumbir a alguém de provar algo que NÃO aconteceu é difícil, e se trata da chamada prova “diabólica”, porque impossível/difícil de ser produzida. Observe como o tema é cobrado em prova:

CESPE - Juiz Federal (TRF 5ª Região)/2017/XIV. Em que consiste a prova diabólica? Quando houver prova bilateralmente diabólica, como deve o juiz proceder? A quem cabe o ônus da prova? Justifique

Boas respostas devem agregar várias informações, por isso é muito bom você saber como o instituto da prova diabólica é tratado no **CPC**:

CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: (...)

Compreenda que o CPC possibilita ao juiz de, diante de uma prova diabólica, **INVERTER** o ônus da prova.

A partir disso, comparando o CPC com o CPP, a pergunta é:

A pergunta a ser respondida nesse tópico é a seguinte:

Seria possível a inversão do ônus da prova no âmbito do processo penal?

A resposta é, em **regra NÃO**, por conta da indisponibilidade dos bens que estão em jogo. Mas cuidado, porque a doutrina aponta uma EXCEÇÃO, qual seja, as **cautelares patrimoniais**. Ex.: art. 4ª, § 2º, Lei de Lavagem de Capitais:

Art. 4ª, § 2º, Lei de Lavagem de Capitais: “O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou

acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

(...)

§ 2o O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”

Assim sendo, no CPP, excepcionalmente e em determinada situação, ocorre LEGALMENTE a INVERSÃO. Para agregar ainda mais informações à sua resposta veja como a professora Ada cuida do tema:

Para ADA PELLEGRINI GRINOVER, essa inversão do ônus da prova "seria representada, portanto, por uma carga mais leve para a acusação do que para a defesa, no sentido de que, para o sequestro, bastarão indícios veementes, enquanto para a liberação será necessária a comprovação da licitude, entendida como exigência de prova plena". O preceito em questão merece interpretação conforme, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência, por estabelecer indevida inversão do ônus da prova.

Assim, deve ser entendido como relacionado ao pedido de restituição durante o curso do processo. Se esse pedido de liberação for formulado antes da decisão, recai sobre o réu, corréu, partícipe ou terceiro de boa-fé o ônus de comprovar a licitude da origem dos bens, mediante a oposição dos embargos previstos no art. 130, I e II, do CPP.

De outro modo, o professor Américo Bedê Freire Júnior, **NÃO** concorda com a inversão do ônus da prova no CPP, porque segundo ele, **NÃO** se trata de questões da esfera civil, mas questões da esfera penal.